

1500971-71.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... evidenciado que estava associado para a prática do narcotráfico. Acrescente-se que Matheus, apesar de primário, está sendo processado em outro feito pela prática do crime de tráfico. Nessa linha, posicionam-se os Tribunais Superiores:

A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500971-71.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500971-71.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA RAYMUNDO e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

MATHEUS LUCAS MARQUES DA SILVA e WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA RAYMUNDO foram denunciados por incursão no caput do art. 33 e caput do art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 23h, na Rua América do Norte, 756, Parque das Américas, nesta cidade de Mauá, os acusados guardavam, tinham em depósito e expunham a venda, para fins de tráfico, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, descritas no auto de exibição e apreensão de fls. 14-5, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, os denunciados associaram-se entre si e com outras pessoas para praticar o crime previsto no art. 33 da Lei Antidrogas.

Recebida a denúncia, os réus foram citados (fls. 113-4) e apresentaram respostas à acusação.

Durante a instrução, as testemunhas arroladas pelas partes foram devidamente inquiridas e os réus interrogados.

Em memoriais finais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal nos termos da denúncia, enquanto a Defesa busca a absolvição ou, ao menos, a fixação das penas no patamar mínimo, reconhecendo-se a atenuante da confissão para os réus e o tráfico privilegiado para Matheus, bem como a fixação de regime inicial semiaberto para Willian, além de regime aberto e a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos para o réu Matheus.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decidido.

Procede a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01-2), boletim de ocorrência (fls. 03-6), auto de exibição e apreensão (fls. 14-5), laudos de constatação (fls. 35-42), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 107-12) e prova oral colhida.

Comprovou-se a autoria.

Interrogados, em solo policial, os réus permaneceram em silêncio (fls. 12-3).

Sob o contraditório, Matheus negou a acusação. Afirmou que reside na primeira casa da viela e alugou a segunda casa para Willian, sendo que as residências ficam no mesmo quintal. Quando da abordagem policial, perguntou se os milicianos tinham mandado e levou um tapa no rosto. Os policiais levaram-no ao Distrito Policial sob a justificativa de que morava no mesmo quintal que o corréu (mídia digital).

Willian, de seu turno, admitiu a prática do tráfico e negou estar associado com Matheus ou terceiros. Alegou que não conhece Matheus (mídia digital).

As versões apresentados pelos réus, contraditórias, estão isoladas do conjunto probatório.

Na fase administrativa, o policial militar Sylvio historiou que (sic) "efetuava patrulhamento de rotina pela rua América do Norte, bairro Parque das Américas, quando deparou com um indivíduo próximo a uma viela, que ao avistar a aproximação da viatura policial tal indivíduo empreendeu fuga, fato que despertou a atenção do depoente, decidindo, então, sair ao encalço do suspeito, conseguindo abordá-lo na rua Texas, altura do numeral 61. Esclarece o depoente que ao detê-lo o agora identificado Wilian Roberto de Oliviera, jogou uma sacola plástica preta no chão. Feita abordagem e revista pessoal no detido, nada de ilícito foi encontrado, mas no interior do saco plástico preto que estava ao seu lado no chão, foi encontrado vinte porção de uma substância esverdeada semelhante a maconha e a quantia de R\$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos) em dinheiro. Perguntado sobre a origem das substâncias encontradas em poder dele, confessou que naquele saco plástico havia várias porções de maconha e aquele local era um ponto para venda de entorpecente e tinha a missão de comercializar substâncias ilícitas naquele local. Perguntado também onde havia adquirido as substâncias ilícitas, confessou que buscava na rua América do Norte, 756, casa 02, bairro Parque das Américas. Diante dessa informação deslocou na companhia do indivíduo detido ao local informado, onde lá foi recebido pela pessoa de Matheus, que questionado sobre a imputação que pesava sobre ele, de fornecer entorpecentes a Wilian, confessou que guardava drogas no interior de sua casa para distribuição naquele ponto de venda. Acrescenta o depoente que Matheus

permitiu o ingresso no seu imóvel, onde lá foi encontrado entorpecentes, dinheiro, três rádios comunicadores, duas máquinas de cartão, papel contendo a contabilidade do comércio ilícito e um aparelho celular. Esclarece também o depoente que durante a conversa com Matheus na porta de sua casa o depoente sentia um forte odor de maconha" (fls. 09-10). Na mesma linha as declarações do policial militar Gustavo (fl. 11).

Em juízo, reiteraram integralmente a dinâmica do ocorrido. Em síntese, narraram que durante patrulhamento de rotina o réu Willian empreendeu fuga ao visualizar a equipe. Em razão da fundada suspeita, decidiram pela abordagem. Durante a fuga, ele dispensou uma sacola preta. Ao ser abordado, confessou ser o "vapor", ou seja, ser o responsável pela venda das drogas. Na sacola, apreenderam parte das drogas e dinheiro. Indagado sobre a procedência do entorpecente, Willian admitiu que estava armazenado em uma residência próxima, indicando a casa e quem estaria no local. Em razão dessas informações, dirigiram-se até o endereço informado, uma viela com três casas, sendo que na casa do meio, de porta azul, residia Matheus. Este, por sua vez, confirmou que naquele local estavam armazenadas as drogas destinadas ao abastecimento das biqueiras da região, confirmando ser ali a "casa bomba". Da porta já era possível sentir um forte odor de maconha. Matheus, então, informou que os entorpecentes estavam escondidos no interior do guarda-roupas e autorizou a equipe a ingressar na residência. O policial militar Sylvio acrescentou que, além do entorpecente, apreenderam dinheiro, rádios de comunicação, celular e máquina de cartão. O policial militar Gustavo esclareceu que, segundo apuraram, a primeira casa da viela estava inabitada e servia como depósito de materiais de construção, pelo que conseguiu observar da janela, e a terceira residência pertencia a um vizinho. Além disso, Gustavo esclareceu que o local onde Willian foi visto pela primeira vez é conhecido como ponto de venda de drogas (mídia digital).

A prova por meio de depoimento de policiais não é desvaliosa, quanto ao actum a que corresponda, pela só condição profissional das testemunhas. Ao revés, estar-se-ia diante de uma acepção processual de pessoas com apoio em predicado genérico. A jurisprudência dos Tribunais é firme no sentido de que não é causa simpliciter de menor credibilidade a circunstância de uma testemunha ser policial. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07).

Observe-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, além de plenamente coerentes, estão em perfeita harmonia àqueles por eles prestados perante a autoridade policial. Ademais, não há qualquer motivo a que não possa ser atribuído total crédito a tais depoimentos. Não há nos autos prova alguma, sequer indícios, de que os policiais tivessem motivo particular, injusto, para incriminar falsamente os réus.

Por outro lado, os réus apresentaram versões inverossímeis e contraditórias.

Descabida a alegação da Defesa quanto à ilegalidade na busca pessoal de Willian, uma vez que os policiais responsáveis pela abordagem afirmaram ter visualizado o réu em uma viela conhecida pela prática do tráfico de drogas, com uma sacola preta, empreendendo fuga ao visualizar a equipe, de forma que justificada as fundadas razões para a busca pessoal.

Também não houve invasão de domicílio.

Há nos autos elementos aptos a indicar que havia fortes indícios da existência de entorpecentes no interior da casa em questão, notadamente pelas declarações informais de Willian, bem como pelo forte odor de maconha exalando já na porta da residência. Não bastasse, os policiais foram uníssonos em afirmar que o réu Matheus autorizou o ingresso da equipe em seu domicílio e indicou o local onde estavam escondidas as drogas.

Cumpra relembrar que o narcotráfico é crime permanente, permitindo-se à autoridade policial, a partir da fundada suspeita, ingressar no interior de domicílio em decorrência do estado de flagrância, sem mandado judicial ou permissão do morador (Ap. 0000990-27.2014.8.03.0006 -AP, Câmara Única, rel. Carlos Tork, 21.06.2016, v.u.).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS [...] DOMICÍLIO - VIOLAÇÃO - FLAGRANTE - ARTIGO 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ALCANCE. Caracterizadas fundadas razões, prévias à realização da diligência, a indicarem, de forma concreta, a ocorrência, no momento, de crime, mostra-se lícita a entrada forçada em domicílio desprovida de autorização judicial. [...] (HC 159017, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 21/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-117 DIVULG 31-05-2019 PUBLIC 03-06-2019 - grifo nosso).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ENTRADA AUTORIZADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, porém, conforme se infere do acórdão impugnado do TJGO, após o recebimento de denúncia anônima sobre o intenso tráfico de drogas naquele endereço, os policiais foram em diligência averiguar o caso, e ao chegarem no local "a entrada na casa teria sido autorizada pelos moradores." A versão é a mesma contida no auto de prisão em flagrante, das declarações prestadas pelos agentes públicos. A ação policial logrou êxito na apreensão de 2 porções de maconha pesando 1,055 kg e 3 de crack pesando 0,554, além de uma balança, celular e um veículo Hyundai HB20, vermelho, placa OMT-3218, com restrição de furto e roubo. 4. São válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agravante. Julgados nesse sentido. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC 111.760/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019 - grifo nosso).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER, QUINTA TURMA,

DJe 28/3/2019). 2. No julgamento do RE n. 603.616, Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) tratar-se de acusado foragido da justiça em outra ação penal também por delito de tráfico de drogas e previamente reconhecido; II) policiais já estavam em diligência para apurar informações recebidas sobre a comercialização de entorpecentes pelo paciente utilizando determinado veículo; e III) fuga do acusado para dentro de casa após a abordagem policial, tentando escapar pela parte de trás da residência, sendo preso neste momento diante do certo realizado pelos policiais que, após, encontraram mais de 9kg de cocaína na residência. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 615.563/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021 - grifo nosso).

Não bastasse, em recente decisão da Suprema Corte no RE 1.342.077, o Ministro Alexandre de Moraes reconheceu a prescindibilidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais:

"Incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE. Diante de todo o exposto, em face do decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, CONHEÇO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO E ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação (itens 7,1, 7.2, 8, 12, e 13 da Ementa) [...]."

No mais, a farta quantidade de droga encontrada e as demais circunstâncias da apreensão, tais como a forma de acondicionamento, o local da abordagem de Willian, ponto de tráfico, além do dinheiro apreendido com os réus e dos rádios de comunicação apreendidos com Matheus, são elementos suficientes de que as drogas eram destinadas ao consumo de terceiros.

Do mesmo modo, há vários dados, somados a elevada quantidade de maconha apreendida, demonstrando que os réus mantinham conduta estável, com divisão de tarefas, a indicar a associação para o tráfico e não mero concurso de agentes.

Segundo apurou-se, a casa de Matheus funcionava como "casa bomba", ou seja, um ponto de armazenamento e distribuição do entorpecente. A estabilidade e permanência restou caracterizada não só pela divisão de tarefas, mas também pela relação de confiança entre os réus, já que Matheus era o responsável por tomar conta das drogas, enquanto Willian ficava encarregado de vender o entorpecente no varejo, entretanto, tinha conhecimento do local onde as drogas eram armazenadas. Cumpre acrescentar que na residência de Matheus foram encontrados também três rádios transmissores, comumente utilizados por indivíduos associados para o narcotráfico. Comprovado, portanto, a associação dos réus, ao menos entre si, para a prática do tráfico. Tal panorama subsume-se ao suporte fático do artigo 35 da Lei nº 11.343/06. Nessa linha:

"HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADES DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CARACTERIZADOS OS ELEMENTOS TIPIFICANTES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. [...] 5. Encontra-se suficientemente demonstrada nos autos a prévia combinação de vontades entre, pelo menos, o paciente e uma corré, de caráter duradouro e estável, necessária e suficiente para configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006. Precedentes. [...] 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedido, em parte." (STF HC 109.708/SP 2ª T. Rel. Min. Teori Zavascki j. 23.06.2015 DJE 03.08.2015).

Ainda:

"É que, a experiência assim está a demonstrar, os criminosos não criam, formalmente, pessoas jurídicas para essa finalidade, não lavram, por óbvio, contratos de associação, a afastar qualquer possibilidade de comprovação documental da reclamada associação. Por outra mão, nem sempre se terá nos autos interceptação telefônica prévia, haja vista que, no mais das vezes, esse tipo de prova só costuma ser produzido, palmar, com a prévia e necessária autorização judicial, quando se está diante de uma associação criminosa para fins narcotraficantes com contornos um pouco mais robustos. No entanto, no dia-a-dia, no comum dos casos, os agentes criminosos associam-se e o fazem em associações que não chegam a ter contornos que chamam a atenção, ao menos em um primeiro momento, das Polícias, Civil ou Militar, mesmo das Guardas Civis. Daí a importância de uma análise meticulosa do que se trouxe aos autos, desde a fase inquisitorial até a fase judicial, a se esperar que, nesta, o obtido anteriormente encontre conforto mínimo a propiciar substrato probatório suficiente para o proferimento de uma sentença condenatória, em 1ª Instância, ou da sua manutenção, em 2ª Instância. E via de regra, está a experiência a revelar que a prova que se encontra à disposição do Magistrado é a de comportas indiciárias, tão maltratada, gratuita e graciosamente, por parte não só da Doutrina, como também da Jurisprudência; como se os indícios não fossem, como são, provas robustas o bastante para sustentar, com folga, a condenação deste ou daquele criminoso enovelado no crime de associação para o narcotráfico." (TJ-SP, Apelação nº 0003469-11.2013.8.26.0451, Rel. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal).

Dessa forma, necessária a condenação nos termos propostos pelo Ministério Público.

Passo à fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base do réu Willian, pela prática do crime de tráfico de drogas, 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes, por tráfico, inclusive (certidão de fl. 47 - proc. 00000008-75.2012) e da elevada quantidade de substância entorpecente apreendida, 437 porções de maconha (1.141,8g), fator que justifica a majoração da reprimenda penal, na medida em que incrementa o potencial ofensivo à saúde pública (bem jurídico tutelado pela norma penal), revelando uma maior reprovabilidade da conduta do agente (STF, HC 73.097, rel. Min. Maurício Corrêa, HC nº 76.543-5, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC nº 35.539, rel. Min. Paulo Medina, HC nº 35.795, rel. Min. Nilson Naves, HC nº 35.159, rel. Min. Hamilton Carvalhido), perfazendo 06 anos de reclusão e 600 dias-multa. Para o réu Matheus, primário, majora-se a reprimenda do crime de tráfico em 1/6, pela quantidade, atingindo 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

No tocante ao crime de associação para o tráfico, fixa-se a pena-base de Matheus no mínimo legal, ou seja, 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, e a pena de Willian 1/6 acima do mínimo, frente aos maus antecedentes acima informados, resultando em 03 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na segunda etapa, considerando a menoridade relativa do réu Matheus (20 anos - fls. 07 e 13), a pena do crime de tráfico retorna ao patamar mínimo de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, enquanto a pena do delito de associação para o tráfico permanece inalterada, em observância à Súmula 231 do STJ.

No tocante ao réu Willian, presente a agravante da reincidência (certidão de fls. 47-8 - proc. 0000699-30.2017), as penas sofrem novo acréscimo de 1/6, perfazendo 07 anos de reclusão e 700 dias-multa para o crime de tráfico e 04 anos e 01 mês de reclusão e 952 dias-multa para o crime de associação para o tráfico.

Ainda nesta fase, não há que se falar em confissão, já que o réu Matheus não admitiu a prática delitativa nem na fase administrativa, nem sob o contraditório.

Em relação ao réu Willian, justifica-se a não incidência da atenuante da confissão, não espontânea e parcial, para o crime de tráfico, em razão de sua inutilidade para o desate da ação penal. Isso porque a confissão de quem foi preso em flagrante, em local conhecido pela venda de entorpecentes e em poder das drogas, bem como buscou falsear a verdade, isentando seu comparsa de responsabilidade e buscando atenuar a sua, não tem o intuito de colaborar para a elucidação dos fatos.

Sobre a necessidade da espontaneidade da confissão, decota-se trecho do voto do v. acórdão proferido pelo eminente Desembargador Ricardo Dip, no julgamento da Apelação Ordinária 1.390.581-8:

"Em acréscimo, confissão do acusado, houve. Espontânea, contudo, não; a que houve, tem caráter de provocada.

É válida –recurso de votos precedentes–, é válida, repito, ainda após a controvertida Reforma do Código Penal em 1984, esta lição de Roberto Lyra:

'A espontaneidade da confissão não diz respeito, é claro, à sua prestação, em que seria redundante a referência...' (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1958, vol. 2, n. 64).

Não fosse assim, sobejaria a lei, porque, como disse Fragoso, 'se o agente confessa sob pressão policial, fato, aliás, comum, nenhuma atenuante será aplicável' (Lições de Direito Penal, ed. Forense, Rio de Janeiro, 1994, Parte Geral, n. 345).

Na mesma linha, disse Mirabete: 'Não basta a confissão para a configuração da atenuante; é necessário que o agente, arrependido, procure a autoridade para a confissão, já que a lei não fala em ato voluntário, mas em confissão espontânea' (Manual de Direito Penal, ed. Atlas, São Paulo, 1997, vol. 1, 7.5.6).

Diz José Antonio Paganella Boschi, comentando o disposto na alínea d, inc. III, art. 65, CP: 'Foge ao sentido do texto, portanto, reconhecer a atenuante quando o agente é preso em flagrante e não tem como negar as evidências em torno da autoria ou imputar a responsabilidade pelo fato a terceiro. Inconfundíveis confissão espontânea e confissão voluntária' (Das Penas e Seus Critérios de Aplicação, ed. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2002, p. 273).

A espontaneidade da confissão –prevista em lei como qualificação necessária do ato confessorio para atuar como causa de atenuação penal– distingue-se da mera voluntariedade da confissão. Não se trata aí do espontâneo como o que procede de um princípio interno juxta naturam agentis, sine deliberatione (Marcelino Zalba), mas do que (disse Cathrein) procedit a princípio interno –ou seja, sem provocação exterior." (TACRIM-SP –11a Câmara)

Manifestou-se, também, o Supremo Tribunal Federal quanto à incompatibilidade da atenuante da confissão espontânea com a situação de flagrância:

"CONFISSÃO ESPONTÂNEA ATENUANTE. Em se tratando de situação concreta em que ocorrida a prisão em flagrante, em razão do transporte de vultuosa quantidade de droga, descabe cogitar da atenuante da confissão espontânea, no que esta última tem

como objetivo colaborar com o Judiciário na elucidação da verdade real". (HC 101.861/MS, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª T., j. em 13.04.2011)

No mesmo julgamento, manifestou-se o Min. Luiz Fux: "Eu também entendo que confissão espontânea e flagrante é *contradictio in terminis*, não dá para conviver; ou confissão voluntariamente ou é preso em flagrante. Não fez favor nenhum à Justiça".

Na mesma direção, precedentes do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Apelação- Tráfico de entorpecentes - Recurso da defesa- Pedido para que o réu possa recorrer em liberdade prejudicado pelo presente julgamento. Condenação mantida. Apreensão de 20 porções de maconha e 61 porções de cocaína- Conjunto probatório seguro e coeso. Dosimetria fixada com rigor- Pena fixada no mínimo legal - Pedido de compensação entre confissão e reincidência- Inadmissibilidade- Confissão que sequer foi considerada na formação do convencimento do julgador- Redutor do art. 41 da Lei de Drogas- Não cabimento- Delação após prisão em flagrante com tóxico- Ausência de colaboração efetiva. Regime inicial Fechado obrigatório para réu reincidente condenado a corporal superior a quatro anos- Sentença mantida. Recurso improvido." (TJSP, AP 1501244-55.2019.8.26.0540, Rel. Des. José Vítor Teixeira de Freitas, j. 29.06.20).g.n.

"[...] Não assiste razão ao apelante quando pleiteia o benefício da atenuante da confissão espontânea, previsto no artigo 65, III, "d", do Código Penal, pois, no caso de que se trata, a confissão, além de absolutamente prescindível para o desate condenatório, em razão da solidez da prova incriminadora produzida sob o crivo do contraditório, bem revelando hábil manejo de autodefesa para tentada incidência da atenuante genérica do art. 65, III, "d", do Código Penal. Assim, por não espontânea e desacompanhada de arrependimento, não permitiria a diminuição da pena pela atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. Nesse sentido, "espontânea é aquela confissão em que o agente, independentemente do concurso da autoridade, busca esta para admitir o delito" (Apelação nº 0001496-21.2009.8.26.0270. Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 26.6.2012). No mesmo sentido: veneranda decisão da Colenda 4ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na Apelação nº 0052302-70.2011.8.26.0050. Rel. Exmo. Des. LUIS SOARES DE MELLO, j. em 16.4.2013). Da mesma forma: STF HC. nº 101.861/MS, Rel. Exmo. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 13.4.2011). No mesmo sentido: PROVA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E VOLUNTÁRIA - DISTINÇÃO. "Não se pode confundir a confissão espontânea com a confissão voluntária do réu surpreendido em plena execução do delito. Esta é uma declaração movida por uma circunstância de evidência dos fatos, aquela pela mera intenção de declarar a verdade". (Apelação nº 566.425/1, Julgado em 01/02/1990, Col. 1ª Câmara, Rel.: ALBERTO MARINO. RJDTACRIM 5/169)" (TJSP; Apelação Criminal 1501404-12.2021.8.26.0540; Relator (a): Freddy Lourenço Ruiz Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/02/2022; Data de Registro: 22/02/2022). g.n.

"(...) Afasta-se o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão. Isso porque Paulo foi preso em flagrante vendendo drogas a um adolescente e outro indivíduo, de modo que sua confissão não foi utilizada para formação da convicção. O flagrante e os depoimentos das testemunhas são suficientes para sustentar sobremaneira o édito condenatório." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500902-44.2018.8.26.0616,, rel. Des. Roberto Porto, j. 18.6.2020, V.U.).g.n.

"(...) Ademais, sobreleva registrar que a referida confissão não foi utilizada pelo magistrado sentenciante como elemento de convicção, não incidindo, assim, na hipótese, a Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. (...) Veja que, para o reconhecimento da finalidade mercantil da droga apreendida com o acusado, o duto

juiz não utiliza de sua confissão a esse respeito, mas sim dos demais elementos de convicção colhidos." (TJSP, 4ª Câmara Criminal, Apelação nº 1500646-88.2020.8.26.0630, rel. Des. Camilo Léllis, j. 22.3.2022, V.U.). g.n.

Apelação criminal – Tráfico de drogas – [...] Dosimetria – pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas. Na segunda fase, exasperação decorrente da reincidência. Confissão que não foi considerada na formação do convencimento do julgador. [...] Preliminar rejeitada. Recurso defensivo improvido. "[...] verificando-se que neste caso, não houve qualquer menção ao teor do interrogatório do acusado para a formação do convencimento do douto Julgador para o deslinde desta ação penal, não há como se acolher o pleito de consideração da referida atenuante de pena, nos termos dos abalizados entendimentos jurisprudenciais referidos." (TJSP; Apelação Criminal 1500255-44.2022.8.26.0540; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2022; Data de Registro: 08/05/2022).

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo duplamente majorado - Incidência da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo comprovada pela prova pessoal - Desnecessidade de apreensão e perícia da arma usada no roubo. (...) Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto não utilizada para fundamentar a condenação - Aumento único no concurso de causas de aumento de pena contemplado no parágrafo único do artigo 68 do Estatuto Penal que não constitui direito subjetivo, tratando-se de faculdade judicial, que, porém, requer justificativa sobre a fração imposta, como no caso penas e regime prisional fechado mantidos. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO." (TJSP, Apelação Criminal nº 1500106-76.2021.8.26.0348, Rel. Des. Adilson Paukoski Simoni, j. 12.04.22).

"(...) Não era mesmo o caso de reconhecimento da confissão, já que parcial e não foi utilizada para convencimento do Juízo, que fundamentou: "não incidência da confissão em relação ao réu Rodrigo, uma vez que ao negar a participação dos corréus Wallace e Paulo, pretendeu ludibriar o Juízo, faltando com a verdade". Assim, a admissão parcial do fato não foi utilizada para formação de convicção do D. Juízo sentenciante, que se limitou a transcrever a versão dada pelos acusados, valendo-se, para se inclinar pela condenação, dos relatos da vítima, dos agentes policiais e da adolescente." (TJSP, Apelação Criminal nº 0013449-58.2017.8.26.0348, Rel. Des. ALEX ZILENOVSKI, j. 9 de março de 2022).

Não bastasse, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu, recentemente:

"Agravos regimental no habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Matéria não analisada na apelação. Óbice à inovação em sede de embargos de declaração. Constrangimento ilegal inexistente, Atenuante da confissão espontânea. Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça STJ. Édito condenatório apoiado em outros elementos. Não incidência. Precedentes. Agravo regimental desprovido. 1. [...] 2. Ainda que controverso o fato de que o paciente assumiu a autoria do delito, esse dado não foi utilizado para a formação do convencimento do julgador. Conforme se verifica, a condenação está amparada no testemunho da vítima e dos policiais condutores da prisão, sendo portanto, inviável a redução da reprimenda. Precedentes, 3. Agravo regimental desprovido (STJ AgRG no HC 648.216/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.06.2021, DJe, 15.06.2021).g.n

"A Súmula 545/STJ prevê que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. Evidenciado que a confissão

informal do réu somente foi explicitada na transcrição dos depoimentos dos policiais condutores, não tendo, todavia, sido utilizada em momento algum para embasar a condenação, sequer citada pelo magistrado sentenciante, deve ser afastada a possibilidade de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal" (AgRg no AREsp 1599610/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 613736/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, j. em 30/03/2021, DJe 13/04/2021).

Na última etapa, incabível o pretendido reconhecimento do instituto da "delação premiada", prevista no art. 41 da Lei nº 11.343/06, para o réu Willian.

Segundo a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, para a incidência do referido instituto, os requisitos do mencionado artigo devem estar presentes cumulativamente. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRETENSÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA RECLUSIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a configuração da delação premiada (art. 41 da Lei de Drogas), é preciso o preenchimento cumulativo dos requisitos legais exigidos. Conforme consignaram as instâncias ordinárias, nenhuma colaboração foi prestada pelo Agravante no sentido de dados acerca do local e da pessoa que lhe forneceu os 21,70 kg de cocaína. 2. A elevação da pena-base foi adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis que, de fato, emprestaram especial reprovabilidade à conduta do Acusado, mormente em se considerando a quantidade e qualidade do entorpecente apreendido. Por consequência, mantém-se o regime fechado (art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RESp 1301255/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 02/12/2013 - grifo nosso).

Na mesma linha, o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06) - RECURSO DEFENSIVO [...] DELAÇÃO PREMIADA - Inviável a redução da reprimenda pela aplicação da delação premiada, quando não preenchidos os requisitos previstos no art. 41 da Lei n.º 11.343/06. [...] Anote-se que o art. 41 da nova lei de drogas menciona requisitos cumulativos para a aplicação da especial causa de diminuição e pela leitura do r. artigo, tem-se que é necessário que a colaboração possa ter efetividade para o desmantelamento de quadrilha ou bando criminoso, ou mesmo para a identificação de outro traficante, possibilitando que se possa oferecer denúncia e processamento do coautor. Desta feita, não há subsídios que apontem que a delação feita pelo apelante tenha se tornado objeto de investigação.

Destaco que, no momento da abordagem, seu comparsa conseguiu fugir e o apelante em nada colaborou para sua identificação ou captura. (TJSP; Apelação Criminal 1500713-03.2018.8.26.0540; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/11/2019; Data de Registro: 18/11/2019).

Na hipótese, não houve qualquer colaboração por parte do réu Willian para descoberta de eventual fornecedor ou outros colaboradores do narcotráfico. A mera indicação do local de armazenamento dos entorpecentes não é suficiente para o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena. Note-se que Willian não admitiu a participação de Matheus no crime de tráfico de entorpecentes, fato confirmado após as diligências policiais.

Registre-se ainda que, na fase inquisitiva e durante a instrução, não houve cooperação alguma por parte do réu. Sobre o tema:

SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT) [...] - DOSAGEM DAS PENAS EM CONSONÂNCIA COM O REGRAMENTO LEGAL, INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS E DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL - REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO À ESPÉCIE, MOSTRANDO-SE INADMISSÍVEL A CONCESSÃO DE QUAISQUER BENESSES - RECURSO DESPROVIDO. [...] Outrossim, no tocante ao pedido de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, anoto que a situação verificada nos autos não se amolda ao referido dispositivo. Não se perca de vista que a ré, em juízo, alterou sua versão dos fatos e alegou que atuava apenas como 'olheira' do tráfico, não contribuindo em momento algum com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, ausente, portanto, qualquer colaboração que permitisse dismantelar o grupo criminoso. Assim, nota-se que a ré apenas admitiu ao ser abordada o que foi constatado pela diligente ação policial e, pelo que se depreende dos relatos dos agentes públicos, indicou o barraco onde estava o restante das drogas e dinheiro pretendendo que com isso fosse 'liberada' pelos agentes públicos, não indicando sequer quem seria o proprietário do local (teria mencionado o nome de "Pamela" na fase de inquérito, porém não forneceu qualquer informação que permitisse a identificação de tal pessoa). [...] (TJSP; Apelação Criminal 1517865-93.2019.8.26.0228; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020 - grifo nosso).

SENTENÇA CONDENATÓRIA DO APELANTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT), [...] - APELO DA DEFESA BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA REDUZIR AS PENAS, ACENANDO COM O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, APLICANDO-SE DO REDUTOR LEGALMENTE PREVISTO NA FRAÇÃO MÁXIMA E A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 41 DA LEI DE DROGAS, COM IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), [...] INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 41 DO MESMO DIPLOMA LEGAL PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS [...] Outrossim, no tocante ao pedido de aplicação do instituto da delação, prevista no artigo 41 da Lei nº 11.343/06, anoto que a situação verificada nos autos não se amolda ao referido dispositivo, uma vez que o réu não colaborou com a identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime. Em verdade, CARLOS afirmou que RICARDO seria mero usuário de entorpecentes, a despeito de o corréu ter admitido em sede policial que era responsável por transportar os entorpecentes (fl. 6), não se insurgindo o Ministério Público a respeito. Tampouco indicou quem seria a terceira pessoa que fugiu por ocasião da abordagem policial, não havendo, portanto, nenhuma colaboração que contribuísse para dismantelar o grupo criminoso. Ressaltando-se, ainda, que as drogas foram localizadas na residência após os policiais sentirem forte odor de maconha vindo do local. [...] (TJSP; Apelação Criminal 0061634-17.2018.8.26.0050;

Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020 - grifo nosso).

Não deve incidir, também, no caso concreto, para o réu Matheus - Willian é reincidente - a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, já que restou evidenciado que estava associado para a prática do narcotráfico. Acrescente-se que Matheus, apesar de primário, está sendo processado em outro feito pela prática do crime de tráfico. Nessa linha, posicionam-se os Tribunais Superiores:

A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente entre os agentes no cometimento do delito, evidenciando, assim, a dedicação do agente à atividade criminosa. Precedentes. (STJ, HC 376997 / RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017 - grifo nosso)

PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE COM BASE NA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. VIABILIDADE. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. PACIENTE QUE SE DEDICA AO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, I, DO CP. PENA DE RECLUSÃO SUPERIOR A QUATRO ANOS. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. O afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 foi alicerçada em elementos concretos, que indicam a dedicação do paciente à atividade criminosa relacionada ao comércio de drogas. [...]" (STF HC 118.380/SP Rel. Min. Teori Zavascki j. 04.02.14 DJU 14.02.14 - grifo nosso).

"Tráfico de drogas praticado sob a vigência da Lei 6.368/1976. Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Paciente que se dedicava à atividade criminosa. Para que a redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 seja concedida, não basta que o agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. O voto do eminente Min. Félix Fischer, relator do habeas corpus ora questionado, muito bem explicitou o motivo pelo qual não foi possível a aplicação daquele benefício ao paciente, ressaltando que 'o tribunal a quo negou provimento ao recurso defensivo, a uma, por entender que o paciente se dedicava a atividade criminosa, fazendo do comércio de drogas seu meio de vida, a duas, porque a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 só se aplicaria àquele que como fato isolado vende substância entorpecente, a três, tendo em vista que a sua aplicação é restrita às condenações ocorridas com base na Lei 11.343/2006, não se podendo, assim, a pretexto de se aplicar a lei mais benéfica, combinar partes diversas das duas normas, porquanto isso implicaria, em última análise, na criação de uma terceira lei'." (STF RHC 94.802 Rel. Min. Menezes Direito j. 10.02.09 DJE 20.03.09 - grifo nosso).

Por fim, frente ao concurso material entre os delitos, estabilizam-se as penas em 08 anos reclusão e 1.200 dias-multa para o réu Matheus e 11 anos e 01 mês de reclusão e 1.652 dias-multa para o réu Willian.

O valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica dos réus.

O regime penitenciário inicial será o fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, bem como a gravidade in concreto dos delitos, notadamente o fato de os réus estarem associados para a

prática de crime equiparado a hediondo, a quantidade de droga apreendida, além das nefastas consequências do narcotráfico à sociedade, potencializador da ocorrência de outros delitos, inclusive, tudo isso a indicar um grau acentuado de culpabilidade, de forma que o regime mais gravoso mostra-se necessário para o cumprimento da pena privativa de liberdade. Pontua-se que Willian é reincidente.

O c. Supremo Tribunal Federal já decidiu da seguinte forma:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA ELEMENTOS CONCRETOS EM DESFAVOR DO RÉU. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME FECHADO ADEQUADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] V - Na hipótese, não obstante a reprimenda final seja igual a 8 anos de reclusão, é inviável a imposição do regime semiaberto, diante da existência de elementos concretos a figurar em demérito do paciente, a saber, o fato de estar associado a organização criminosa e exercer função específica dentro do grupo, consoante salientado pelo Tribunal a quo. De rigor, pois, a manutenção do regime inicial fechado. vejamos: Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 440.040/RJ, relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 26/4/2018.)

"HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA. Possibilidade de fixar regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes. Ordem denegada." (STF - HC 119.515/AC - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 03.12. - DJU 10.12.13).

Pela mesma razão não é hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou de concessão do sursis, insuficientes para prevenção e reprovação da conduta.

Posto isso, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na ação penal para CONDENAR o réu MATHEUS LUCAS MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 08 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.200 dias-multa, no unitário mínimo, e o réu WILLIAN ROBERTO DE OLIVEIRA RAYMUNDO, qualificado nos autos, às penas de 11 anos e 01 mês de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.652 dias-multa, no unitário mínimo, ambos por incursão no caput do art. 33 e caput do art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Denego aos réus o apelo em liberdade, mantidos os fundamentos da custódia cautelar.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para a destruição das substâncias entorpecentes e dos rádios apreendidos (fls. 14-5), bem como oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência dos valores ao Fundo Nacional Antidrogas, eis que vinculados à narcotraficância, nos termos dos arts. 63 e 72 da Lei n.º 11.343/2006.

Quanto ao telefone e máquinas de cartão apreendidos (fls. 14-5), nos termos dos artigos 122 e 123 do Código de Processo Penal e 516 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, aguarde-se eventual provocação do interessado no prazo de 90 dias do trânsito em julgado, desde que comprovada a propriedade. Decorrido o prazo, sem manifestação, determino o perdimento dos bens, para posterior alienação em leilão ou destruição, se o caso.

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA